

2012년도 제49회 변리사 제2차 시험 특허법 풀이 답안

안녕하세요! 장현욱 변리사입니다.

지난 몇 개월간 인고의 시간을 거쳐, 힘겹게 시험을 치르시느라 정말 수고하셨습니다.

먼저, 여러분들 모두 끝까지 포기하지 않고 정진하셨기에,

영광의 날에 인고의 향이 물씬 베어 있는 열매를 맺게 되시길 진심으로 기원합니다.

시험장에서의 체감난이도와는 다르겠지만, 전체적인 난이도는 객관적으로 작년과 큰 차이는 없다고 보나, B-1문과 관련하여, 재심부분은 대부분의 분들이 평상시에 많이 다루어보지 않아 처음 문제를 접하셨을 때 적잖게 당혹감을 느끼셨을 것이라고 생각합니다. 다만, 주어지는 법전을 활용해서 문제에서 묻고자 하는 내용들에 대해 적절하게 인용하여 기재하셨다면, 중간 이상의 점수를 기대해 볼 수 있을 만큼, 조문의 내용과 이에 대한 적용이 주를 이루는 문제였다고 봅니다.

그 외 A-1, A-2, B-2문의 경우, 대부분 학원의 g/s를 통해 접해보셨거나 차분히 생각하시면 충분히 해결할 수 있는 문제들이라고 사료되어, 주 논점의 큰 길에서 벗어나지 않으셨을 거라는 믿음을 가져봅니다.

이하에는, 2012년 제49회 변리사 2차 시험의 특허법에 대한 풀이답안이 있습니다.

본 풀이답안은, 합격의 법학원 특허법 전임강사 김성호 변리사와 함께 검토하였으며, 설혹 이하의 내용에 본인이 답안지에 작성하지 않은 내용이 포함 내지는 불포함 되어 있다거나, 논점 전개의 흐름에 있어 다소간의 차이가 있다 하더라도 심리적으로 크게 동요하실 필요는 없으며, 스스로의 논리를 믿으시면 분명히 좋은 점수를 받으실 것이라고, 강사가 아닌 선 경험자의 입장에서 꼭 말씀을 드리고 싶습니다.

다시 한번 정말로 수고하셨다는 말과 함께,

여러분들 모두에게 합격의 영광이 있기를 진심으로 기원합니다.

<A - 1문>

[문 제]

甲은 물질 X의 발명자로서 이를 2010. 11. 1. 미국에 특허출원 한 후 특허법 제54조의 조약에 의한 우선권을 주장하여 [청구항 1]에 물질 X를, [청구항 2]에 물질 X를 관절염 치료에 이용하는 발명 Y를 기재하여 2011. 10. 5. 우리나라에 특허출원 하였다. 乙은 2009년부터 물질 X에 대한 연구를 시작하였으며 2011. 5. 1. 화학분야 학회의 학술대회에서 물질 X와 물질 X의 제조방법인 Z에 대하여 발표하고, 2012. 4. 5. 공지에외주장을 수반하여 [청구항 1]에 물질 X를 [청구항 2]에 물질 X의 제조방법인 Z를 기재하여 우리나라에 특허출원하였다.

- (1)甲의 특허출원과 乙의 특허출원이 1특허출원범위를 만족하는지에 대해 각각 설명하시오.(10점)
- (2)乙의 특허출원이 공지에외주장의 시기적 요건을 만족하는지의 여부에 대하여 설명하시오.(6점)
- (3)甲이 출원한 [청구항 2]의 발명 Y가 특허를 받기 위해 만족해야 할 특허요건과 명세서 기재시 유의점에 대하여 설명하시오(14점)

[의 견]

A-1문의 설문 별 주 논점은, 다음과 같습니다.

설문(1)은 1특허출원범위의 만족여부에 대한 구체적 판단, 설문 (2)는 공지에외주장의 시기적 요건의 개정내용을 알고 있는지 여부, 설문 (3)은 의약용도발명의 특허요건 및 명세서 기재방법을 실시하는 것이었습니다. 이들은 모두 학원수업시간이나 g/s를 통해서 강조되던 내용에 관한 문제라고 판단됩니다.

설문 (1)에서는, 1특허출원범위에 대한 의의 및 시행령6조의 내용과 관련된 판단방법을 충분히 기술하되, 甲의 1특허출원의 범위 만족여부와 관련해서 조약우선권주장의 적법여부에 대한 판단이 수반되어야 한다고 보여지며, 이는 만일 조약우선권주장이 부적법한 경우라면 甲의 1특허출원의범위 판단에 있어서 물질 X가 乙의 행위로 인해 공지 된 것으로 취급되어, 시행령 제6조의 선행기술에 비해 개선된 것일 것의 요건이 불비될 수 있기 때문이며, 이와 궤를 같이하여 乙의 공지에외주장의 적법여부도 1특허출원범위에 영향을 미치는 점에서 판단이 수반되어야 하나, 설문 (2)에서 공지에외주장의 시기적 요건의 검토와 관련된 문제가 출제되었으므로 설문(2)와의 중복을 피하기 위해, 적절하게 언급만을 해주는 답안작성요령이 요구될 것으로 판단됩니다.

설문 (2)에서는, 공지에외주장의 시기적 요건의 개정내용을 실시하고, 이것을 만족하고 있는지 여부에 대해 적용하는 문제인 바, 문제의 초점이 공지에외주장의 요건 중 '시기적 요건'에 국한되어 물어보고

있기 때문에 이에 중점을 두어 개정내용의 경과규정 및 개정취지 등을 배점에 맞게 충실하게 기재하는 것이 중요하다고 보여집니다. 이 부분은 수업시간을 통해 여러 번 말씀을 드렸기에 내용적으로는 모두 숙지하고 잘 기재하셨겠지만, 배점이 크지 않은 6점짜리 문제이므로 주 논점인 공지예외주장의 시기적 요건의 개정내용에 대해서 보다 자세히 기술하시되, 기타 다른 절차나 그들의 적법여부에 대해서까지 장황하게 기재하실 필요는 없다고 판단됩니다.

설문 (3)에서는, 의약용도발명임은 쉽게 간파하셨겠지만, 문제 어디에도 의약용도발명임이 제시되어 있지 않기 때문에, 먼저 甲의 청구항 2에 기재된 '물질 X를 관절염 치료에 이용하는 발명 Y'가 의약용도발명임을 선 검토하는 것이 필요하겠으며, 이후에 의약용도발명의 특허요건 및 명세서 기재방법에 대한 내용을 작성하는 것이 필요한 문제였습니다. 또한, 발명이 '물질 X를 관절염 치료에 이용하는 발명 Y' 라고 다소 모호한 형태로 주어진 바, 이를 물질이 아닌 방법으로 이해하셨다면 의료행위의 산업상 이용가능성 판단에, 자칫 공간을 많이 할애하게 될 우려가 존재하므로, 물질발명에 해당한다는 판단 및 간단한 전제가 필요하다고 보여지며, 그 외에는 알고 계시는 판례를 적절한 목차에 따라 실시하시면 충분한 문제라고 판단됩니다.

[풀 이]

I. 설문 (1)에 대하여 (10) – 시행령 제6조의 요건 및 1특허출원의 범위 만족여부 판단

1. 문제의 소재

甲과 乙의 1특허출원범위 만족여부와 관련하여 제45조 및 시행령 제6조를 살펴보고, 카테고리가 상이한 경우의 판단방법 및 선행기술에 비해 개선된 것인지 여부를 중심으로 이를 검토한다.

2. 1특허출원범위의 의의 및 취지 – 제45조

하나의 총괄적인 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1출원을 할 수 있다. 이는 PCT·EPC 등에서의 발명의 단일성과 같은 개념이다. 절차의 편의 및 관련기술의 용이한 관리를 위함이다.

3. 1특허출원의 요건 – 시행령 제6조의 검토

1특허출원을 하기 위해서는, ①청구된 발명 간에 기술적 상호관련성이 있을 것 ②청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가질 것 및 ③기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비해 개선된 것일 것의 요건을 만족하여야 한다.

4. 1특허출원의 구체적 판단방법 – 카테고리가 상이한 경우 등

(1)독립항 간의 기술적 특징을 비교하되, 기술적 특징은 동일하지 않더라도 상응하기만 하면 되며, 기술적 특징은 선행기술보다 개선된 것이어야 하므로, 선행기술을 먼저 고려한 후에 단일성을 판단한다.

(2)특히, 11년 개정 심사지침서는, 선행기술에 비해 개선되어야 하는 기술적 특징은 해당 출원 전 선행기술에 비해 신규성과 진보성을 구비하게 되는 기술적 특징을 말한다고 규정하고 있다.

(3)나아가, 발명의 카테고리가 다르더라도 단일성이 만족될 수 있다. 예컨대, 물건발명에 대한

독립항과 ①물건을 사용하는 방법에 관한 독립항, ②물건을 생산하는 방법에 관한 독립항간에는 단일성을 만족하는 것으로 본다.

5. 甲의 1특허출원범위 만족여부 - 설문 (1)의 해결

(1)청구항 1은 물질 X이고, 청구항 2는 물질 X를 이용하는 발명 Y으로서, ①물질 X가 공통되므로 다른 사정이 없는 한 기술적 상호 관련성이 인정될 것이고, ②물질 X라는 동일한 기술적 특징이 존재하므로, ③기술적 특징인 물질 X가 선행기술에 비해 개선된 것이라면 甲의출원은 1특허출원범위를 만족할 것이다.

(2)이와 관련하여, 甲의 특허출원일 전에 乙에 의해 물질 X가 공지 등이 되었는바, 甲의 물질 X가 선행기술에 의해 신규성이 부정되어 공통되는 기술적 특징이 아니라고 볼 수 있는지가 문제되나, 甲의 우선권 주장은, 출원인이 甲으로 동일하고, 물질 X의 발명이 공통되며, 미국의 선출원일로부터 1년 내의 출원이므로, 미국출원의 정규성·최선성 요건 및 절차적 요건에 문제가 없다면, 적법한 우선권 주장에 의해 물질 X의 판단시점이 乙에 의한 공지시점 이전인 2010. 11. 1로 소급되는바, 이는 문제되지 않을 것이다.

6. 乙의 1특허출원범위 만족여부 - 설문 (1)의 해결

청구항 1은 물질 X이고, 청구항 2는 물질 X의 제조 방법 Z로서, ①물질 X가 공통되므로 다른 사정이 없는 한 기술적 상호 관련성이 인정될 것이고, ②물질 X라는 동일한 기술적 특징이 존재하며, ③설문 (2)에서 그 적법성이 검토되는 乙의 공지에외주장에 의해 물질 X의 공지는 선행기술이 될 수 없으므로, 다른 사정이 없다면 선행기술에 비해 개선된 것으로서, 甲의 특허출원은 1특허출원범위를 만족할 것이다.

II. 설문 (2)에 대하여(6) -공지에외주장의 시기적 요건의 개정내용에 대한 검토

1. 문제의 소재

공지에외주장의 시기적 요건이 최근 특허법의 개정으로 변경되었는바, 개정내용을 검토하여 乙의 공지에외주장의 시기적 요건의 만족 여부를 판단하기로 한다.

2. 공지에외주장의 의의 및 취지(제30조)

특허출원 전에 이미 공지 등이 된 발명이라도 제30조의 일정한 요건을 갖춘 경우 신규성 및 진보성의 판단 시 공지 등이 되지 않은 것으로 간주하는 제도이다. 발명의 조기공개를 유도하고, 의사에 반한 공지의 경우 출원인의 보호를 위해 인정된다.

3. 공지에외주장의 시기적 요건의 검토

(1)구 특허법에서는 공지 등이 된 날로부터 6개월 내에 출원 및 주장 할 것을 요하였다.

(2)그러나, 2012.3.15.자로 시행된 한-미 자유무역협정의 특허 관련 합의사항에 따라, 특허법의 공지에외 적용기간이 종전 6개월에서 12개월로 연장되었다. 발명의 공개는 기술발전 및 축진을 통한 산업 발전에 이바지한다는 특허법 목적에 부합하는 개정으로서, 출원인의 자발적 공개 행위에 대해 특허를 받을 수 있는 기회를 확대하여 발명의 조기공개를 위한 환경을 조성하기 위함이다.

(3)다만, 출원일이 2012. 3. 14. 이전인 경우에는 종전대로 6개월의 공지에외적용기간이 적용된다.

4. 설문 (2)의 해결

(1)따라서, 乙의 특허출원일은 2012. 3. 15. 이후인 2012. 4. 5. 로서, 물질 X 및 그 제조 방법 Z가

화학발명 학회를 통해 불특정 다수인에게 공지된 2011. 5. 1. 로부터 12개월 내의 출원에 해당하는바, 乙의 공지에외주장은 시기적 요건을 만족한다고 볼 것이다.

(2)나아가 출원 시 취지기재서면을 제출하고 출원일로부터 30일 내에 증명서류를 제출하였다면 전체적으로 적법한 공지에외주장출원이 될 것이다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여(14) – 의약용도발명 해당여부 및 그 요건 검토

1. 문제의 소재

청구항 2의 발명이 의약용도발명에 해당하는지 여부를 확정하고, 이와 관련된 특허요건으로서 발명의 성립성, 산업상 이용가능성, 신규성 내지 진보성의 문제를 검토하며, 명세서 기재시의 유의점과 관련하여 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위의 기재에 대한 대법원 判例를 검토한다.

2. 甲이 출원한 【청구항2】의 발명Y가 의약용도발명의 해당하는지 여부 검토

甲이 출원한 【청구항2】의 발명 Y는, 물질 X자체가 지니는 관절염 치료 특성을 발견하여 그 성질을 이용, 물질 X를 관절염 치료라는 의약적 용도에 이용하는 발명인바, 의약용도발명에 해당한다.

3. 甲이 출원한 청구항 2의 발명 Y가 특허를 받기 위한 요건의 검토 – 성립성 등 - 설문 (3)의 해결

(1)발명의 성립성 검토(제2조1호)

1)甲의 청구항 2의 발명 Y는, 종래의 물질 X로부터 어떠한 새로운 속성을 발견하여, 이를 기존에 존재하지 않았던 관절염 치료라는 새로운 용도로 이용하는 발명이므로, 그 과정에 있어서 창작적 요소가 존재하는 경우에는 이를 주장·입증하여 용도발명으로 성립성을 인정받을 수 있을 것이다.

2)나아가, 대법원 判例는, 출원 전에 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같이 특별한 사정이 없는 한 데이터가 기재된 실험예를 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 발명이 완성되었다고 볼 수 있다고 판시하므로, 종래의 물질 X의 관절염 치료의 용도는 새로운 용도로서 약리기전이 명확히 밝혀지지 않은 것으로 볼 수 있는바, 이에 대한 실험예 또는 구체적 기재가 수반되어야 성립성을 인정받을 수 있을 것이다.

(2)산업상 이용가능성의 검토(제29조1항본문)

인도적 또는 윤리적 차원에서 인체를 필수구성요소로 하는 수술, 치료, 진단방법과 같은 순수의료기술은 산업상 이용가능성이 인정되지 않는다는 것이 일반적이나, 대법원 判例는, 의료기구, 장치, 의약품이나 인간으로부터 채취한 것을 처리하거나 분석하여 데이터를 수집하는 방법은 산업상 이용가능성이 있는 것으로 보고 있으므로, 의약품에 해당하는 발명 Y는, 문제되지 않을 것이다.

(3)신규성 및 진보성의 검토(제29조1항2항)

물질X의 관절염 치료에 이용하는 용도 자체가 甲의 특허출원 전에 공지된 적이 없고, X를 관절염 치료 용도로 이용하는 것이 공지된 물질 X 및 물질 X의 제조방법 Z로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다는 사정도 존재하지 않는 바, 신규성 및 진보성은 모두 부정되지 않는 것으로 볼 것이다.

(4)불특허발명 및 1특허출원범위의 검토(제32,45조)

설문 (1)에서 검토한 바와 같이, 1특허출원범위를 만족하며, 甲의 출원발명이 공서양속에 위반된다는 사정 없는바 불특허발명에도 해당되지 않는다.

4. 명세서 기재시의 유의점 검토 - 대법원 判例 등 - 설문 (3)의 해결

(1)발명의 상세한 설명(제42조 3항 1호)

1)이는, 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다

2)대법원 判例는, 실험의 과학이라 불리는 화학발명이나 의약발명 등의 경우에는 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 데이터가 기재된 실험례가 기재되어 있지 않으면 통상의 기술자가 명세서로부터 그 발명을 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 명세서 기재불비에 해당한다고 판시하며, (2001후65)

3)대법원 判例는, 의약에 관한 용도발명에 있어서는 일반적으로 물질명, 화학구조만으로 그 작용효과를 명확히 이해하는 것이 곤란하므로, 그 약리효과에 대한 객관적이고도 구체적인 기재를 하는 것이 명세서의 필수적인 요건이라고 판시한다.(94후869)

4)따라서, 출원 시 최소한, 물질 X의 관절염 치료로의 이용과정에 있어서의 실험례 및 그 약리효과에 대한 구체적인 기재가 명세서에 기재되어야 할 것이다.

(2)특허청구범위(제42조 4항 각호)

1)대법원 判例는, ①의약의 용도발명에 있어서 특정물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로 발명의 특허청구범위는 특정물질의 의약용도를 대상질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 하나, ②의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있더라도 발명의 상세한 설명 및 기술상식에 의하여 의약적 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 제42조 4항 2호의 명확성의 요건을 충족한 것으로 본다고 판시한다.(2006후3564).

2)따라서, 청구범위에 관절염 치료에 이용하는 물질 X를, 관절염 치료용 물질 X 등으로 기재하여 그 용도를 대상질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 할 것이다.

(3)나아가, 대법원 判例는, 시험례의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 부적법하다고 판시하므로, 출원 시부터 위와 같은 실험례 등의 기재가 포함되도록 주의를 기울여야 할 것이다.

<A - 2문>

[문 제]

A 발명의 특허권자 甲이 B를 실시하고 있는 乙에 대하여 2011. 11. 24. 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

(1)확인대상발명(B)의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되지 않은 경우의 절차에 대하여 설명하시오.(14점)

(2)만약, 甲이 확인대상발명(B)의 설명서 및 도면을 보정한 경우 요지변경에 해당하는지 여부에 대하여 설명하시오.(6점)

[의 견]

A-2문의 설문 별 주 논점은 다음과 같습니다.

설문 (1)은 수업시간에도 자주 강조했던 권리범위확인심판의 확인대상발명의 특징에 관한 대법원 判例 및 그 절차를 직접적으로 묻는 문제였으며, 설문 (2)는 심판청구인의 보정에 대한 요지변경 여부와 관련 제140조2항본문과 判例를 알고 있는지에 관한 문제였습니다.

설문 (1)에서는, '절차'에 관하여 주되게 묻고있는 바, 확인대상발명의 특징과 관련된 判例 이외에 심판원의 조치 등의 내용을 함께 기술하시는 것이 필요하다고 판단됩니다.

또한, 설문 (2)에서는, 140조2항본문의 내용을 주시고, 대법원 및 특허법원의 요지변경 관련 判例들을 함께 기재하여 요지변경인지 여부를 판단하는 것이 필요하다고 판단되며, 설문의 경우 甲이 실제 B를 실시하고 있는 乙에게 B를 확인대상발명으로 하여 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였으므로, 확인의 이익과는 무관하다고 볼 수 있겠으나, 보론 정도로 제140조 2항 3호를 써준다면 좋은 인상을 줄 수 있겠습니다.

[풀 이]**I. 설문 (1)에 대하여(14) – 확인대상발명의 특정여부에 관한 대법원 判例 및 심판원의 절차 검토****1. 문제의 소재**

확인대상발명의 특징과 관련한 최근 대법원 판례의 태도를 검토하고, 불특정 된 것으로 볼 수 있는 경우의 특허심판원의 절차에 대해 보정명령 및 보정명령 없이도 본안에 대한 판단이 가능한지 여부 등을 구체적으로 검토한다.

2. 사안의 확인대상발명의 특정여부 검토 – 최근 대법원 判例의 적용

(1)권리범위확인심판의 청구인은 심판청구 시에 특허발명과 대비될 수 있는 확인대상발명의 설명서

및 필요한 도면을 심판청구서에 첨부하여 제출하여야 한다(제140조 3항).

(2)대법원 判例는, 확인대상발명의 구성요소를 전부 기재할 필요는 없고 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정하면 되며, 이는 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단 함에 필요한 정도는 되어야 한다고 판시하여, 특허발명과 확인대상발명의 대비에 있어서만 그 특정여부를 판단한다고 판시하였다.

(3)다만, 최근 대법원 判例는, 위와 유사한 사안에서, 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다고 하여, 확인대상발명 그 자체로도 특정이 되어야 함을 판시 한 바가 있다.

(4)사안에서, 확인대상발명 B의 일부 구성이 불명확하여 그 자체가 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되지 않은 경우이므로, 확인대상발명은 특정되지 않은 것으로 볼 것이다.

3. 불특정 된 경우의 구체적 절차의 검토 - 보정명령 및 본안 판단 거부

(1)대법원 判例는, 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원에서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 한다고 판시하며,

(2)또한, 대법원 判例는, 확인대상발명이 구체적으로 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 한다고 판시한다.

(3)사안에서, 특허심판원은 확인대상발명의 불특정 여부를 직권으로 조사하여 밝혀야 하며, 확인대상발명 B의 일부 구성이 불명확하여 불특정 된 경우이므로, 심판청구인 甲에게 보정을 명할 것이다.

(4)나아가, 특정에 대한 보정명령 없이도 본안 판단이 가능한지가 문제될 수 있으나, 대법원 判例는, 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 그 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리 범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 할 것이라고 판시하므로, 불가할 것이다.

4. 설문 (1)의 해결

따라서, 확인대상발명 B가 불특정 된 것이므로, 특허심판원은 甲에게 보정을 명할 것이며, 이에 불응 하거나 또는 보정에 의하여도 특정되지 않는 경우 심판청구를 각하 할 것이다.

II. 설문 (2)에 대하여(6) - 심판청구서 보정에 관한 제140조 2항 본문 등의 검토

1. 문제의 소재

심판청구서의 보정과 관련하여 제140조 2항 본문의 규정을 살펴보고, 요지변경이 아닌 것으로 보는 각급 판례를 검토하여, 甲의 확인대상발명의 설명서 및 도면의 보정이 요지변경 여부를 판단한다.

2. 보정의 범위 검토 - 제140조 2항 본문

특허발명과 대비될 수 있는 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 심판청구서에 첨부하여

제출하여야 하는데(제140조 3항), 이러한 확인대상발명의 설명서 및 도면이 포함된 심판청구서의 보정은 원칙적으로 요지변경이 아닌 범위 내에서만 허용된다(제140조 2항 본문).

3. 요지변경인지 여부 판단에 대한 각급 법원 判例의 태도

(1)대법원 判例는, 불명확한 부분을 구체화 하는 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 추가한 것 특허발명과 대응되는 수치를 정확히 보정하는 것은 심판청구의 전체적인 취지로 볼 때 발명의 동일성이 유지되는 것으로 보아 요지변경에 해당되지 않는다고 판시해 동일성 범위를 넓게 해석하고 있다.

(2)나아가, 특허법원 判例는, 당초 물건만으로 특정된 확인대상발명에 그 특허발명과 동일한 생산방법을 추가로 기재하는 확인대상 발명의 보정은 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로 보아 요지변경에 해당되지 않는다고 판시한다.

4. 설문 (2)의 해결

따라서, 갑의 확인대상발명(B)의 설명서 및 도면의 보정이 상기 대법원 및 특허법원 判例가 판시하는 정도의 보정에 해당한다면 요지변경이 아닌 것으로 볼 수 있을 것이나, ②그 외에 동일성의 범위를 벗어나는 정도의 보정에 해당한다면 요지변경에 해당할 것이다.

5. 보론 - 제140조 2항 3호의 적용가부

07년 개정법의 제140조 2항 3호는 적극적 권리범위확인심판에서 확인의 이익이 없는 경우 피청구인의 실제 실시발명과 동일하게 하는 보정을 규정한 것이므로, 실제 B를 실시하는 乙에게 B를 확인대상발명으로 하여 적극적 권리범위확인심판을 청구한 본 사안에서는 그 적용이 불가할 것이다.

<B - 1문>

[문 제]

甲은 발명 P(A+B+C+D)에 대하여 2009. 2. 20. 특허를 취득하였다. 乙은 2009. 6. 1. 부터 발명 P를 판매하여 왔다. 2009. 7. 10. 甲은 乙이 자신의 특허를 침해하고 있다고 판단하여, 침해를 금지해 줄 것을 요청하는 경고장을 乙에게 발송하였다. 乙은 발명 P 판매를 중지하고, 甲의 특허발명 P는 A+B라는 비교대상발명 1과 C+D라는 비교대상발명 2를 결합하여 당업자라면 용이하게 발명할 수 있는 것이기 때문에 진보성을 결여한 발명이라고 주장하면서 특허무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2010. 6. 1. 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 대하여 甲은 2010. 6. 25. 특허법원에 특허무효심결의 취소를 구하는 심결취소소송을 제기하였다. 이 사건에 관여하는 기술심리관 丁은 사건을 검토하던 중 甲의 특허발명이 자신이 특허청 심사관으로 재직 중 특허등록결정을 하였던 발명이라는 사실을 확인하였다. 2011. 2. 2. 특허법원은 원고의 청구를 기각하는 판결을 내렸다. 甲은 대법원에 상고할 것을 포기하였고 결국 특허법원의 판결은 확정되었다. 이후 甲은 기술심리관 丁이 특허청 심사관으로서 자신의 특허출원을 심사하였던 사실을 알고 재심을 청구하였다.

- (1) 甲의 재심청구가 재심사유에 해당되는지 설명하십시오(8점)
- (2) 甲의 특허권이 재심에 의하여 회복된다면 乙이 발명 P를 실시하기 위한 요건을 설명하십시오(12점)
- (3) 기술심리관 丁이 취했어야 할 적절한 조치를 설명하십시오(5점)
- (4) 위에 기술된 사실관계와는 달리 만약 甲이 소송의 심리중에 기술심리관 丁이 특허청 심사관으로부터 甲의 특허발명의 심사에 관여했었다는 사실을 알게 되었을 때 甲이 취할 수 있는 조치를 설명하십시오 (5점)

[의 견]

B-1문의 설문 별 주 논점은, 다음과 같습니다.

설문 (1)은 제척사유 있는 기술심리관의 소송 관여가 재심사유인지 여부, 설문 (2)는 재심에 의해 회복된 경우의 효력제한(제181조) 및 통상실시권(제182조), 설문 (3)은 회피를, 설문 (4)는 제척재판신청을 묻고 있다고 보시면 되겠습니다.

B-1문과 관련하여 앞서 말씀 드린 것처럼, 재심부분은 대부분의 분들이 평상시에 많이 다루어보지 않아 처음 문제를 접하셨을 때 적잖게 당혹감을 느끼셨을 것이라고 생각합니다. 다만, 주어지는 법전을 활용해서 문제에서 묻고자 하는 내용들에 대해 적절하게 인용하여 기재하셨다면, 중간 이상의 점수를 기대해 볼 수 있을 만큼, 조문의 내용과 이에 대한 적용이 주를 이루는 문제였다고 보여지며, 대부분의 분들이 비슷하게 기재하셨을 것이라고 판단되므로, 본 문제에서 큰 점수 폭이 생기지는 않을 것으로 판단되니, 설사 자신 없게 기재하셨다고 하더라도 크게 마음 쓰시지는 않으시길 바랍니다.

설문 (1)에서는, '재심청구가 재심사유에 해당하는지 여부'를 주되게 묻고 있으므로, 재심청구의 적법여부나 절차를 장황하게 기술하기 보다는 재심사유에 대해 주로 판단하는 것이 필요하며, 특히

기술심리관에 대해서는 심판관의 제척사유인 제148조를 제188조의2의 1항을 통해 준용하는 형태로 기술심리관의 제척을 규정하므로 이러한 내용의 판단이 필요하겠으며, 기술심리관에 대한 제척사유가 특허법 178조2항을 통해 준용되는 민사소송법상 재심사유에 해당하는지와 관련하여 직접적인 규정이 없으므로 이들의 관계에 대하여 어느 정도 언급을 하시는 것이 필요하다고 판단됩니다.

설문 (2)에서는, 주된 논점은 제182조 적용이라고 판단되며, 배점이 12점인 관계로 제181조와 기타 제3자의 실시 방안 및 사안의 포섭을 부가하여 기술하는 식으로 작성하면 될 것으로 판단되며,

설문(3) 및 (4)에서는, 기술심리관이 취할 조치로서 회피를, 심판청구인의 조치로서 제척재판신청을 각각 적용되는 조문과 함께 그 내용을 기술하시면 될 것으로 판단됩니다.

[풀 이]

I. 설문 (1)에 대하여(8) – 제척사유 있는 기술심리관의 소송 관여가 재심사유에 해당하는지 여부

1. 문제의 소재

기술심리관인 丁이, 자신이 특허청 심사관으로 재직 중 특허등록결정을 하였던 발명에 대한 특허무효심판의 심결취소소송에 관여한 것이 재심사유에 해당하는지를 판단하기 위해, 특허법 제148조, 제178조, 제188조의 2를 검토한다.

2. 재심의 의의 및 취지(法178조)

확정심결에 중대한 하자가 있는 경우 다시 심리하여 줄 것을 구하는 비상의 불복방법이다. 특허법은 법적 안정성과 구체적 타당성의 확보라는 상반된 이념의 조화를 위하여 재심제도를 규정하고 있다.

3. 재심사유의 검토

(1)제178조2항에서는, 재심사유로서 민사소송법 제451조를 준용한다. 따라서, 특허법상 재심에 있어서는 민사소송법상 재심사유에 의한다.

(2)다만, 일반재심사유에 해당하는 사실을 상소로 주장하였으나 기각된 경우 또는 이를 알고도 상소로 주장하지 않은 경우에는 그 사유로 재심을 청구할 수 없다(재심의 보충성).

4. 기술심리관 丁이 제척사유를 가지는지 여부 – 제148조

(1)제148조 6호는, 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우에는 심판 관여로부터 제척됨을 규정하고 있으며, 제188조의 2 1항에서는, 기술심리관의 제척에 이를 준용함을 규정한다.

(2)사안에서, 기술심리관 丁은 자신이 특허청 심사관으로 재직 중 특허등록결정을 하였던 발명에 대한 특허무효심판의 심결취소소송에 관여하였으므로, 위 규정에 의해 제척사유를 가진다.

5. 설문 (1)의 해결 – 甲의 재심청구가 재심사유에 해당하는지 여부

따라서, 민사소송법 제451조 1항 2호에서는 법률상 그 재판에 관여할 수 없는 법관이 관여한 때를 재심사유로 규정하고 있고, 특허법 제178조2항 및 제188조의 2 1항을 고려해 볼 때, 특허법상 재심에

이를 준용하고 있으므로, 제188조의2 1항에 따라 준용되는 148조6호의 제척사유 있는 기술심리관 丁이 재판에 관여하였음을 주장한 甲의 재심청구는, 특허법 178조2항에 따라 준용되는 민사소송법 451조 1항 2호에 해당하여, 재심사유에 해당한다고 볼 것이다.

II. 설문 (2)에 대하여(12) – 재심에 의해 회복한 특허권의 효력 제한 및 그 선사용자의 통상실시권

1. 문제의 소재

乙은 재심에 의해 회복된 甲의 특허발명을 실시하고자 하는 자로서, 그 실시를 위한 요건과 관련하여 제181조 및 제182조의 각 요건을 구체적으로 검토하고, 나아가 기타 요건으로서 실시가 가능한 경우를 추가적으로 검토한다.

2. 실시권 없이 실시하는 방법 – 제181조 - 설문 (2)의 해결

(1)제181조는, 재심에 의해 회복한 특허권의 효력 제한에 대하여 규정하고 있는데, 사안에서 무효로 된 甲의 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우에 해당하므로, 제181조 1항 1호에 해당하여 그 효력이 제한될 수 있다.

(2)따라서, 乙은, 심결이 확정된 후 재심청구의 등록 전에 선의로 발명 P를 ①수입 또는 국내에서 생산하거나 취득(제181조 1항 본문), ②선의로 실시(제181조 2항 1호), ③물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(제181조 2항 2호), 및 ④방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(제181조 2항 3호)의 요건을 갖춘 경우라면 각각 발명 P를 실시할 수 있을 것이다.

3. 실시권을 통해 실시하는 방법 – 제182조 등 - 설문 (2)의 해결

(1)제182조는, 재심에 의해 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권을 규정하고 있는데, 사안에서 무효로 된 甲의 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우에 해당하므로, 제181조 1항 1호에 해당한다.

(2)따라서, 제181조 1항 1호에 해당하는 경우에 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가짐을 규정하는 제182조가 적용될 수 있다.

(3)따라서, ①甲으로부터 침해의 경고를 받은 乙이, 심결이 확정된 후 즉, 특허법원의 판결이 확정된 후 甲에 의한 재심청구의 등록 전에 발명 P의 실시사업 또는 그 사업의 준비를 하였고, 선의로 즉 재심사유가 존재하는지 여부를 알지 못하였고, 그러한 실시사업 또는 그 사업의 준비가 국내에서 이루어졌다면, 乙은 제182조의 선사용자에 의한 통상실시권의 각 요건을 만족하여, 적법한 실시권을 가지고 발명 P를 실시할 수 있을 것이다.

(4)나아가, 乙은, 甲과 특허발명인 발명 P의 실시에 대해 별도의 실시권 설정 계약을 통한 실시도 가능할 수 있을 것이다.

4. 기타 요건의 검토

허락, 화해, 중재, 등의 별도 조치를 통해서도 乙은 발명 P를 실시할 수 있을 것이다.

Ⅲ. 설문 (3) 및 (4)에 대하여(10) – 기술심리관의 회피 및 제척재판신청

1. 문제의 소재

설문 (3)에서는 기술심리관 丁이 취했어야 할 적절한 조치로서 회피가, 설문 (4)에서는 甲의 조치로서 기술심리관의 제척재판신청 및 상소가 가능할 수 있는바, 이하 검토한다.

2. 기술심리관의 회피에 관한 규정의 검토

제188조의2 3항에서는, 기술심리관이 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정할 경우에는 특허법원장의 허가를 얻어 회피할 수 있음을 규정하고 있고, 그러한 제척 사유에 대해서는 제188조의2 1항에서 제148조를 준용하고 있다.

3. 甲의 제척신청에 관한 규정의 검토

제188조의 2 1항에서는, 민사소송법 제42조 내지 제45조를 기술심리관의 제척·기피에 관하여 준용함을 규정하여, 기술심리관에 대해 제척재판신청이 가능함을 규정하고 있고, 그러한 제척 사유에 대해서는 특허법 제148조를 준용하고 있다.

4. 설문 (3)의 해결

따라서, 기술심리관 丁은, 자신이 사건을 검토하던 중 甲의 특허발명이 자신이 특허청 심사관으로 재직 중 특허등록결정을 하였던 발명이라는 사실을 소송에서의 심리도중 발견하였으므로, 위 규정에 따라 특허법원장의 허가를 얻어 회피를 하였어야 할 것이다.

5. 설문 (4)의 해결

(1)따라서, 甲이 소송의 심리 중에 기술심리관 丁이 특허청 심사관으로서 자신의 특허발명의 심사에 관여했었다는 사실을 알게 되었고, 이는 제148조 6호 및 제188조의 2 1항에 의한 기술심리관의 제척사유에 해당하여, 甲은 재판부에 대해 제척재판신청(제188조의 2 1항 준용 민사소송법 제42조)을 할 수 있을 것이다.

(2)나아가, 위와 같은 제척재판신청이 받아들여지지 않은 경우에는 제척재판신청에 대한 즉시항고의 불복이 가능하므로(제188조의 2 1항 준용 민사소송법 제47조) 이로써 불복하거나, 특허법원의 본안의 종국판결에 대해 상소를 제기하면서 이를 다룰 수 있을 것이다(행정소송법 제8조에 의해 민사소송법 제424조 1항 2호 준용).

<B - 2>

[문 제]

甲은 乙의 특허발명 A+B+C에서 비교적 중요하지 않은 구성요소 C를 생략하여 A+B만으로 된 물건을 생산하여 판매하고 있다.

(1)甲의 실시가 乙의 특허발명을 침해하는지의 여부에 대해 학설의 논거와 판례의 태도를 검토하시오.(12점)

(2)위와 같이 乙의 특허발명에서 일부 구성요소를 생략한 경우 균등론의 적용이 가능한지 여부에 대하여 판단하시오 (8점)

[의 견]

B-2문의 설문 별 주 논점은 다음과 같습니다.

설문 (1)은 생략침해 인정여부에 대한 논의를 직접적으로 묻고 있으며, 설문 (2)는 구성요소 C의 생략을 치환으로 보아 균등론을 적용할 수 있는지에 관한 문제입니다.

설문 (1)의, 생략침해 인정여부에 대한 논의는 수업시간 전 미리 공지해드리는 방식을 통해 충분히 암기를 하셨을 것으로 판단되어 대부분 잘 쓰셨을 것이며, 침해 여부를 묻고 있으므로 문언침해에 대한 간략한 검토가 필수적으로 선행되어야 합니다.

설문 (2)에서는, 균등론의 의의 및 적용요건에 관한 일반론을 기재 하시되, 주 논점으로는 구성요소의 치환에 구성요소의 생략이 포함되는지 여부에 대한 검토로 보시면 되겠습니다. 구성요소 C를 생략한 경우, 생략된 구성요소 C의 기능이나 방식 등을, 생략되지 않은 A+B에서 실질적으로 수행하고 있다는 사정이 있는지 여부에 따라 생략을 치환으로 볼 수 있는지가 달라지고 이에 따라 균등론의 적용여부가 달라질 수 있으므로, 이것에 대한 간략한 검토가 필요한 문제였다고 판단됩니다.

[풀 이]**I. 설문 (1)에 대하여(12) – 생략침해 인정여부에 대한 논의의 검토****1. 문제의 소재 – 문언침해 성립여부 등**

甲이 실시하고 있는 A+B만으로 된 물건은, 특허발명의 구성요소 중 C가 결여된 실시해에 해당하므로, 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 의하여 정하여지고(法97조), 구성요소원비의 원칙 상 문언침해에는 해당하지 않는다. 다만, 생략발명에 대해 침해(이하, 생략침해)를 인정할 수 있다면 甲의 실시태양이 乙의 특허권에 대한 침해를 구성하는 바, 이하 생략침해의 인정여부에 대해 검토한다.

2. 생략발명의 의의 및 해당여부

특허발명의 구성요소 중 중요도가 낮은 구성요소를 생략하여 특허발명의 작용·효과보다 열악하거나 이와 동일한 효과를 가져오도록 실시하는 형태를 말하는데, 사안에서 甲은 乙의 특허발명에 있어서 비교적 중요하지 않은 구성요소인 C를 생략한 형태로 실시하고 있는바, 생략발명에 해당할 수 있다.

3. 생략침해의 법리에 대한 논의 검토 - 학설 및 判例

(1)학설은, ①특허권자의 실효적 보호를 위해 이를 인정해야 한다는 <긍정설>과, ②발명의 구성요소에 대한 중요도 판단은, 주관적 사정에 의할 수밖에 없다는 점에서 법적 안정성을 해침을 이유로 하여 생략침해를 부정하는 <부정설>이 대립한다.

(2)대법원 判例는, 발명은 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술적 사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 판시하여 생략침해를 부정하는 듯한 취지로 판시한다. 다만 과거 대법원 判例 중에는, 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 일부 구성을 생략하거나 설계변경을 통하여 도달할 수 있는 정도에 불과한 것도 등록고안의 권리범위에 속한다고 판시한 예가 있다.

(3)생각건대, 생략침해를 인정하는 것은 과거 중심한정주의 해석방법과 같아지게 되는 점, 구성요소를 청구항에 기재할 것인지의 여부는 출원인의 자유의사에 맡겨진 점, 발명의 특성에 필요하다고 기재한 후 등록 후에 중요치 않다고 하여 이를 제외하여 권리범위를 주장하는 것은 法42조6항의 취지에 정면으로 반하는 것이며, 구성요소 중요도에 대한 판단기준이 모호한 점 등을 고려할 때, 주변한정주의에 입각하여 이를 부정하는 대법원 判例가 타당하다고 본다.

4. 설문 (1)의 해결

따라서, 甲의 A+B가 중요하지 않은 구성요소 C의 생략에도 불구하고 乙의 특허발명에 비해 열악 또는 동일한 효과를 가져온다면 생략발명에 해당할 수 있지만, 이러한 경우에도 생략발명에 의한 침해는 특허법상 인정되지 않는바, 甲의 실시는 乙 특허발명의 침해에 해당하지 않을 것이다.

II. 설문 (2)에 대하여(8) - 구성요소의 생략이 균등론에서의 치환에 해당할 수 있는지 여부

1. 문제의 소재

특허발명에서 일부 구성요소를 생략한 경우의 균등론 적용여부에 관하여 균등론의 적용요건에 관한 대법원 판례의 태도를 검토하고, 구성요소의 생략을 치환된 것으로 볼 수 있는지에 관해 특허법원 판례의 태도를 검토한다.

2. 균등론의 의의·취지 및 요건의 검토 - 대법원 判例 등

(1)주변한정주의의 기초 하에 구성요소완비의 원칙을 엄격히 적용할 경우, ①특허권자의 실효적 보호가 미흡하고, ②특허청구범위에 모든 실시태양의 기재가 불가능하다는 점에서 균등물의 범위까지 침해를 인정하는 이론으로서 명문의 규정은 없으나 判例를 통해 인정하고 있다.

(2)대법원 判例는, 적극적 요건으로, ①과제해결원리가 동일할 것 ②치환가능성이 있을 것 ③치환자명성이 있을 것을, 소극적 요건으로, ④확인대상발명이 자유실시기술이 아니어야 하며,

⑤확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외 되었다는 특단의 사정이 없어야 한다고 판시하며, 적극적요건은 특허권자가, 소극적 요건은 (가)호발명 실시자가 주장입증 요한다.

3. 구성요소의 생략을 치환된 것으로 보아 균등론을 적용할 수 있는지 여부

(1)생략발명은 구성요소가 생략된 경우에 대한 것이고, 균등침해는 구성요소가 치환 내지 변경된 경우에 대한 것이므로, 일응 구성요소의 치환 내지 변경에는 구성요소의 생략이 포함되지 않는 것으로 볼 수 있다.

(2)따라서, 생략된 요소의 기능, 방식 및 효과를, 생략되지 않은 다른 요소에서 실질적으로 수행하고 있다고 인정되는 경우라면, 구성요소의 생략을 치환 내지 변경으로 보아 균등침해가 성립될 수도 있다 볼 여지도 있겠으나, 그러한 사정이 없이 구성요소가 결여된 경우에는 치환에 대한 요건이 불비되어 과제해결원리가 동일하다거나 치환가능성이 있다고 볼 수 없으므로, 균등론의 요건을 만족하지 않아 균등침해에 해당하지 않는다고 볼 것이다.

4. 설문 (2)의 해결

사안의 경우 생략된 구성요소 C의 기능이나 방식 등을 A+B에서 실질적으로 수행하고 있다는 사정이 존재하지 않는 바, 乙의 특허발명에서 비교적 중요하지 않은 일부 구성요소인 C를 생략한 것은 치환에 해당하지 않고, 결국 균등론의 적극적 요건의 불비로 인해, 균등침해의 적용이 불가할 것이다.

앞서 말씀드린바와 같이, 본 풀이답안의 내용에 본인이 답안지에 작성하지 않은 내용이 포함 내지는 불포함 되어 있다거나, 논점 전개의 흐름에 있어 다소간의 차이가 있다 하더라도 심리적으로 크게 동요하실 필요는 없으며, 스스로의 논리를 믿으시면 분명히 좋은 점수를 받으실 것이라고, 강사가 아닌 선 경험자의 입장에서 꼭 말씀을 드리고 싶습니다.

답안을 작성하면서 수험시절의 제 모습이 많이 생각나서, 시험이 진행되는 시간동안 마음속으로 진심을 담아 여러분들을 응원했습니다. 이제 친숙했던 하얀 답안지와 검은펜은 여러분의 손을 떠났으니, 공부하시느라 지금껏 참아왔던 여러 가지 것들을 발표 때까지 걱정 없이 즐기시길 바랍니다. 또한 누차 말씀 드리지만, 시험을 치른 느낌과 결과는 차이가 있을 수 있으니, 낙담하거나 혹은 자만하지 마시고 여러분들께 주어진 휴식의 시간을 마음껏 즐기시길 권합니다.

질문이나 고민이 있으신 분들은 unthink83@naver.com으로 메일 주시면 답변드리겠습니다.
정말 수고하셨습니다^^